

1501193-66.2022.8.26.0628

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: RAFAEL RAUCH

Comarca: Itapevi

Foro: Foro de Itapevi

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/10/2022

... com a acusada se destinavam ao tráfico, não havendo espaço para eventual desclassificação da conduta praticada.

A ré estava na posse de quantidade e variedade de entorpecentes incompatível para a figura de um simples usuário. A par disso, estava em local notoriamente conhecido como ponto de tráfico de drogas. Certamente estava ali para o fim de vender drogas na ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapevi

Foro de Itapevi

Vara Criminal

Rua Vereador Dr. Cid Manoel de Oliveira, 405, Itapevi-SP - cep 06660-280

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501193-66.2022.8.26.0628 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501193-66.2022.8.26.0628

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante -

2177235/2022 - DEL.POL.ITAPEVI, 25868250 - DEL.POL.ITAPEVI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GRAZIELA PRISCILA DE MOURA CARRO e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RAFAEL RAUCH

Vistos.

VIVIANE GUADALUPE DOS SANTOS e GRAZIELA PRISCILA DE MOURA CARRO, qualificadas nos autos da Ação Penal em epígrafe que lhes move a Justiça Pública, foram denunciadas como incurso no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

Isso porque, no dia 30 de junho de 2022, por volta das 13h00min, na Rua Serra de Itaberaba, altura do n.º 25, Jardim Rosemary, nesta cidade e Comarca de Itapevi, as rés traziam consigo drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

As rés foram notificadas (f. 82-83) e apresentaram defesa prévia (f. 87-89).

Não sendo caso de rejeição da denúncia ou de absolvição sumária, a exordial acusatória foi recebida por decisão datada de 24 de agosto de 2022 (f. 90-91).

As rés foram citadas, dando-se seguimento à persecução penal em Juízo.

Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas, tendo-se interrogado as rés ao

final (f. 125). Na sequência, encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais (f. 123-124).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

DECIDO.

Trata-se de ação penal na qual o Ministério Público imputa às acusadas a prática da infração penal prevista no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

Não havendo questões de admissibilidade a serem analisadas e, no mais, presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo ao exame do mérito.

A pretensão acusatória é procedente.

A materialidade do delito está comprovada pelo auto de exibição e apreensão de f. 12, que atesta terem sido apreendidos os entorpecentes em posse das acusadas, bem como a quantia de R\$ 60,00 em dinheiro.

As substâncias entorpecentes foram submetidas a exame pericial (f. 75-77), sendo que o resultado foi positivo para "crack", "cocaína" e "maconha", drogas de uso proscrito no Brasil.

A autoria também é inconteste.

Os policiais civis, ouvidos sob o crivo do contraditório, foram contestes nos pontos essenciais e confirmaram a ocorrência dos fatos descritos na denúncia.

Relatam que estavam em patrulhamento de rotina em local conhecido como ponto de tráfico, quando avistaram as acusadas em atitude suspeita e as observaram por um tempo. Viram as rés sendo abordadas por algumas pessoas, que lhes entregavam algo e, na sequência, elas se revezavam para ir até uma viela buscar um objeto, que entregavam a essas pessoas. Realizaram, então, a abordagem. Em posse das acusadas havia uma quantia em dinheiro. Foram até a viela onde elas pegavam os objetos e, lá, havia diversas porções de drogas.

A ré Viviane Guadalupe dos Santos, em seu interrogatório, confessa a prática do delito.

A acusada Graziela Priscila de Moura Carro, por sua vez, alega em seu interrogatório que não estava traficando drogas e tinha apenas ido levar uma marmitta para a corré, sua companheira, no momento da abordagem.

Está isolada nos autos, contudo, a versão da ré de que não estava traficando as drogas.

Aliás, em juízo, afirma não conhecer os policiais que realizaram a abordagem, não sabendo indicar por que razão eles a acusariam falsamente.

E nada há nos autos que indique eventual intenção espúria dos policiais de incriminar injustamente a acusada. Assim, seus depoimentos merecem credibilidade e são valiosos para a condenação. Entendimento contrário acarretaria a ruína do sistema de segurança pública do Estado.

Frise-se, nesse passo, que as circunstâncias da abordagem, noticiadas nos depoimentos dos policiais civis, permitem presumir que as drogas apreendidas com a acusada se destinavam ao tráfico, não havendo espaço para eventual desclassificação da conduta praticada.

A ré estava na posse de quantidade e variedade de entorpecentes incompatível para a figura de um simples usuário. A par disso, estava em local notoriamente conhecido como ponto de tráfico de drogas. Certamente estava ali para o fim de vender drogas na região.

Ademais, os policiais foram uníssonos ao afirmar que observaram as acusadas por um tempo e as viram em revezamento para ir buscar as drogas na viela onde elas estavam guardadas.

Nesses termos, nota-se que a negativa da ré em nada desqualifica a versão dos policiais, já que ausentes relatos contrapostos ou contraditórios.

As provas, portanto, são bastantes para a condenação das duas acusadas.

No que tange à aplicação da causa de diminuição de pena, prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006, atento aos recentes julgados dos tribunais superiores sobre o assunto, revejo posicionamento anterior e passo a não vislumbrar inconstitucionalidade na incidência deste privilégio.

Explica-se.

A Terceira Seção do C. STJ, embora não tenha se pronunciado diretamente sobre a

inconstitucionalidade ou não da causa especial de diminuição de pena em tela, ao revisar o REsp n.º 1.329.088/RS, afetado para julgamento pelo rito dos recursos repetitivos (arts. 1.036 e seguintes do CPC), no Tema n.º 600, firmou a seguinte tese: "O tráfico ilícito de drogas na sua forma privilegiada (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) não é crime equiparado a hediondo".

Com a revisão da tese anterior, o tribunal superior cancelou seu enunciado de súmula n.º 512, que assim dispunha: "A aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 não afasta a hediondez do crime de tráfico de drogas".

Foram, outrossim, compiladas as seguintes teses sobre o tema, na edição n.º 131 da Jurisprudência em Teses do C. STJ:

21) O tráfico ilícito de drogas na sua forma privilegiada (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) não é crime equiparado a hediondo. (Tese revisada sob o rito do art. 1.036 do CPC/2015 - TEMA 600)

22) A causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas só pode ser aplicada se todos os requisitos, cumulativamente, estiverem presentes.

23) É inviável a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 quando há condenação simultânea do agente nos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, por evidenciar a sua dedicação a atividades criminosas ou a sua participação em organização criminosa.

25) Diante da ausência de parâmetros legais, é possível que a fração de redução da causa de diminuição de pena estabelecida no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 seja modulada em razão da qualidade e da quantidade de droga apreendida, além das demais circunstâncias do delito.

45) A natureza e a quantidade da droga não podem ser utilizadas simultaneamente para justificar o aumento da pena-base e para afastar a redução prevista no §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, sob pena de caracterizar bis in idem.

46) A utilização concomitante da quantidade de droga apreendida para elevar a pena-base e para afastar a incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, por demonstrar que o acusado se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa, não configura bis in idem, tratando-se de hipótese diversa da Repercussão Geral - TEMA 712/STF.

48) A utilização da reincidência como agravante genérica é circunstância que afasta a causa especial de diminuição da pena do crime de tráfico, e não caracteriza bis in idem.

Em todos esses enunciados, bem como no Tema Repetitivo n.º 600, o C. STJ admitiu indiretamente a viabilidade de incidência da circunstância privilegiadora do art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006, desde que observados cumulativamente os requisitos do dispositivo.

Também o STF firmou tese admitindo a aplicação do privilégio ao delito de tráfico, no julgamento do Tema n.º 712 de Repercussão Geral, no qual se firmou a seguinte tese: "As circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena".

Desse modo, nada há que se falar sobre eventual inconstitucionalidade da norma disposta no art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006.

No caso concreto, todavia, é incabível a aplicação da forma privilegiada do tráfico, eis que não observados cumulativamente todos os requisitos para sua aplicação.

Com efeito, as rés são reincidentes específicas no crime de tráfico ilícito de entorpecentes, de acordo com as certidões de f. 30-31 e 32-34.

Inviável, nesses termos, a incidência da circunstância privilegiadora.

Nessa conjuntura, verifica-se que há subsunção das condutas das acusadas ao tipo penal previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, uma vez que, com vontade e consciência, traziam consigo e vendiam as porções de drogas indicadas na denúncia, sem autorização legal ou regulamentar.

O fato é ilícito, pois reprovado pela lei penal, sendo que não foram alegadas ou comprovadas quaisquer causas justificantes.

As denunciadas eram maiores de 18 anos de idade (imputáveis), tinham potencial consciência da ilicitude e, nas circunstâncias, era-lhes exigida conduta diversa.

Presente, portanto, a culpabilidade.

Assim, passo a aplicar a pena, seguindo o método trifásico previsto no art. 68 do CP.

Inicialmente destaco que este Juízo, para a estipulação da pena base e o cálculo do aumento decorrente de eventual circunstância judicial – inclusive para a aferição de pena de multa cominada isolada ou cumulativamente –, leva em consideração o resultado do intervalo, abstratamente previsto pela lei, entre a pena mínima e a pena máxima, seguido da divisão por oito, conforme ensina Ricardo Augusto Schmitt: “O critério que vem sendo utilizado pelos Tribunais Superiores repousa numa situação prática e simples, que tem resultado a partir da obtenção do intervalo da pena prevista em abstrato ao tipo (máximo – mínimo), devendo, em seguida, ser encontrada sua oitava parte (1/8), ou seja, dividir o resultado obtido por 8 (oito), em vista de ser este o número de circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal. Com esse raciocínio, chegamos ao patamar exato de valoração de cada uma das circunstâncias judiciais (com absoluta proporcionalidade), o qual servirá de parâmetro para o julgador promover suas análises individuais” (Sentença Penal Condenatória. Teoria e Prática. Podivm. 6ª edição. Salvador/Bahia. 2011. p. 115/116).

A par disso, para a hipótese específica destes autos, incide o disposto no art. 42 da Lei n.º 11.343/06, que assim dispõe, in verbis: “O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”.

Neste cenário normativo, verifica-se que dois vetores do art. 42 da Lei de Drogas já estão inseridos expressamente nos parâmetros do art. 59 do CP – “personalidade e conduta social do agente”. Outrossim, tem-se que “a natureza e a quantidade da substância ou produto” podem ser analisadas no contexto das “circunstâncias” do delito, outro vetor do art. 59 do CP.

Assim, e pela necessidade da “preponderância” prevista no art. 42 da Lei n.º 11.343/06, alvitra-se valorar a personalidade e a conduta social do agente, assim como as circunstâncias do delito, com um peso mais significativo.

Como ressaltado anteriormente, costuma-se considerar o intervalo, abstratamente previsto pela lei, entre a pena mínima e a pena máxima, seguido da divisão por oito. Todavia, para preponderância aqui perseguida, prudente que a divisão seja feita por 11, uma vez que as circunstâncias do art. 42 da Lei de Drogas podem ser enquadradas em três vetores, tal como delineado acima – personalidade, conduta social e circunstâncias.

Fazendo isso, porém, deve-se dar aos vetores preponderantes o peso de 2/11, e aos demais, o de 1/11.

Assim, nos termos dos arts. 59 do CP e 42 da Lei n.º 11.343/06, à culpabilidade, aos antecedentes, aos motivos e às consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima (irrelevante em se tratando de crime vago como o tráfico de drogas), deve-se atribuir o peso de 1/11, constituindo 5/11 da pena-base; à conduta social e à personalidade do agente, assim como às circunstâncias, deve-se aplicar o peso de 2/11, configurando 6/11 da pena-base.

Desse modo, estará garantida a aplicação preponderante do art. 42 da Lei de Drogas, bem como assegurada, de forma mais escorreita e técnica, a individualização da pena.

Todavia, é necessário ressaltar que a fração indicada não deve ser aplicada de forma precisa, matematicamente. Trata-se, na verdade, de mero parâmetro para a fixação da reprimenda penal, de modo que as circunstâncias do caso concreto podem ensejar a exasperação maior ou menor da pena – ou maior ou menor compensação em caso de vetores favoráveis.

Feitas essas observações, à dosimetria da pena.

Pois bem, ambas as acusadas possuem uma condenação já transitada em julgado, a qual, porém, será sopesada na segunda fase da dosimetria (f. 30-34).

Por outro lado, importante ressaltar que, em seus interrogatórios, afirmaram ser usuárias de drogas e consumi-las com frequência. Tal circunstância é desfavorável às condutas sociais das denunciadas, já que, além de traficarem drogas, financiam

indiretamente esse delito equiparado a hediondo, crime esse que vem, cada vez mais, corroendo famílias e a própria sociedade.

As demais circunstâncias do art. 59 do CP não são desfavoráveis às réas, ou são normais ao tipo penal.

Nesse contexto, havendo uma circunstância judicial preponderante negativa (conduta social) para ambas as acusadas, fixo as penas bases em 06 anos e 08 meses de reclusão – e 666 dias-multa.

Na segunda fase, há a agravante da reincidência para as duas réas, tendo em vista que, conforme certidões de f. 30-31 e 32-34, as acusadas cometeram o crime em tela depois de terem sido condenadas definitivamente por outro delito, tal como dispõem os arts. 63 e 64, I, ambos do CP.

No ponto, ressalto que as acusadas são reincidentes específicas, pois foram condenadas anteriormente também por tráfico ilícito de entorpecentes, o que reclama uma exasperação mais severa do que a fração habitualmente utilizada de 1/6.

Assim, ante a agravante da reincidência específica, aumento a reprimenda da ré Graziela Priscila de Moura Carro em 1/5, fixando-a provisoriamente em 08 anos de reclusão – e 799 dias-multa.

Quanto à acusada Viviane Guadalupe dos Santos, além da agravante da reincidência específica, há a atenuante da confissão espontânea para ser considerada, na forma do art. 65, III, “d” do CP, tendo em vista que a acusada confessou em juízo a prática do delito.

Assim, o C. Superior Tribunal de Justiça pacificou, no julgamento do EREsp n.º 1.154.752/RS (DJe 4.9.2012), o entendimento no sentido de que é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes, de acordo com o art. 67 do CP. Contudo, por se tratar de reincidência específica, deixo de compensar as circunstâncias e exaspero a reprimenda em 1/7, fração menos gravosa que a utilizada comumente, fixando-a, provisoriamente, em 07 anos, 07 meses e 12 dias de reclusão – e 761 dias-multa.

Por fim, na última fase, não havendo causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas, fixo as reprimendas, agora definitivamente, em: a) 08 (oito) anos de reclusão – e 799 (setecentos e noventa e nove) dias-multa para a acusada Graziela Priscila de Moura Carro; e b) 07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 12 (doze) dias de reclusão – e 761 (setecentos e sessenta e um) dias-multa para a acusada Viviane Guadalupe dos Santos.

O valor do dia-multa fica estabelecido em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente no país na data dos fatos, considerada a presumida precariedade da situação financeira das denunciadas, valor a ser atualizado quando do efetivo pagamento.

De acordo com o art. 2.º, § 1.º, da Lei n.º 8.072/90, fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade.

Ressalte-se, nesse passo, que é inconstitucional a Lei n.º 12.736/2012, que determina a consideração da detração penal para fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade.

Isso porque viola o princípio constitucional da isonomia, já que, aplicando-se a referida lei, haverá situações em que pessoas condenadas exatamente às mesmas penas e pelos mesmos crimes terão tratamento totalmente diferente em situações iguais.

Assim, o sentenciado condenado à pena privativa de liberdade, e que tenha sido preso provisoriamente, terá abatido o período pelo próprio Juiz da Condenação para fins de progressão, podendo ser diretamente promovido de regime sem a observância do seu comportamento carcerário (requisito subjetivo). Por outro lado, o condenado que não tenha cumprido prisão provisória deverá obter a progressão com o preenchimento dos requisitos do artigo 112 da Lei das Execuções Penais, a serem analisados pelo Juiz das Execuções Criminais. Há, portanto, dois pesos e duas medidas, ou seja, pessoas sendo tratadas de forma totalmente diferente em situações iguais, violando, assim, o princípio constitucional da isonomia (CF, art. 5.º, caput).

Dessa forma, deixo de aplicar a Lei n.º 12.736/2012.

A detração deverá ser observada pelo juízo da execução, não havendo qualquer prejuízo às acusadas.

Mantenho a custódia cautelar das denunciadas, pois não modificadas as situações que determinaram a sua necessidade. Recomendo as rés na prisão onde se encontram. Incabível a substituição ou a suspensão condicional da pena privativa de liberdade (CP, arts. 44, inciso I, e 77, caput).

Em razão do exposto, julgo procedente a pretensão acusatória para:

- a) condenar a ré VIVIANE GUADALUPE DOS SANTOS, já qualificada, ao cumprimento da pena de 07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 12 (doze) dias de reclusão – e 761 (setecentos e sessenta e um) dias-multa, pela infração ao art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, a ser cumprida em regime inicial fechado; e
- b) condenar a ré GRAZIELA PRISCILA DE MOURA CARRO, já qualificada, ao cumprimento da pena de 08 (oito) anos de reclusão – e 799 (setecentos e noventa e nove) dias-multa, pela infração ao art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, a ser cumprida em regime inicial fechado.

O valor do dia-multa fica estabelecido em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo federal vigente no país na data dos fatos, valor a ser atualizado quando do efetivo pagamento.

Expeçam-se as guias de execução provisória.

Deixo de fixar a verba mínima indenizatória do art. 387, IV, do CPP, pois se trata de crime vago.

Determino a perda dos bens apreendidos a favor da União, nos termos dos arts. 91, II, do CP e 63, I, da Lei n.º 11.343/2006.

Custas pelas rés, em proporção (CPP, art. 804), no valor de 100 UFESPs (Lei n.º 11.608/2003, art. 4.º, § 9.º, “a”), cuja exigibilidade fica suspensa em razão de estarem litigando sob o pálio da assistência judiciária gratuita, que agora lhes fica deferida, anotando-se.

Após o trânsito em julgado:

- (a) lancem-se os nomes das rés no rol dos culpados ou instituto equivalente;
- (b) expeçam-se as guias de execução definitiva;
- (c) oficie-se ao E. Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo, comunicando a condenação das rés, com suas devidas identificações, acompanhadas do inteiro teor da presente sentença, para cumprimento do quanto disposto pelo art. 71, § 2º, do Código Eleitoral combinado com o art. 15, inciso III, da Constituição Federal;
- (d) oficie-se ao Senad, nos termos do art. 63, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006; e
- (e) arquivem-se os autos com as anotações e comunicações necessárias.

P.I.C.

Itapevi, 21 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA